

1500396-45.2019.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2368110/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500396-45.2019.8.26.0580 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500396-45.2019.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2368110/2019 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 9184839 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2189/19/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2368110 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2189/19/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2368110 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2189/19/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2368110 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2189/19/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MANOEL DOS ANJOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

RAFAEL MANOEL DOS ANJOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta de 01:40h, na Rua Vicente Fernandes Figueiredo, 711, Vila Fabiano, nesta cidade e Comarca de Assis/SP, guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 19 porções de cocaína embaladas, totalizando o peso aproximado de 8,72 g, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Eis o relato da exordial acusatória:

Segundo se apurou, no dia 22 de dezembro de 2019, policiais militares realizavam

abordagem de rotina em um bar localizado no endereço indicado no preâmbulo, quando perceberam que o denunciado, que caminhava em direção ao referido bar, ao avistar os policiais tentou retornar, sendo então abordado.

Os militares realizaram revista pessoal, sendo encontrada uma porção de cocaína e R\$ 20,00 (vinte reais) em posse do acusado. Ato contínuo, dirigiram-se ao bar, que é de propriedade do denunciado, e lá encontraram mais 18 (dezoito) porções de cocaína e R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), sendo certo que RAFAEL afirmou ser proprietário da droga localizada e que realizava sua venda em seu bar.

A quantidade e natureza das drogas apreendidas, forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias da prisão, demonstram a destinação do entorpecente ao tráfico de drogas.

Notificado (fl. 78), o réu apresentou defesa prévia (fls. 90/94). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 95/96).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 118/119 e 138/139).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 164/168 e 169/174).

II - Fundamentação

A preliminar de nulidade da prova não merece prosperar.

Sabido que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria de votos, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Assim, com essa decisão, tem-se por superada a orientação jurisprudencial segundo a qual, sendo o tráfico de crime permanente, o encontro de droga no interior da casa caracteriza a situação de flagrante e, por via de consequência, o ingresso na casa estaria legitimado, ainda que não houvesse qualquer dado objetivo prévio, que indicasse a ocorrência do crime.

Entretanto, a despeito disso, no caso em tela, como se depreende do atento exame da prova, o local onde encontradas as demais porções da droga era um bar, local que, apesar de o réu alegar que utilizava para sua moradia, não se insere no conceito legal de casa, que nos é fornecido pelo art. 150, § 4º, do Código Penal, segundo o qual a expressão "casa" para compreende: I) qualquer compartimento habitado; II) aposento ocupado de habitação coletiva e III) compartimento não aberto ao público. Um bar, como se sabe, é um espaço aberto ao público em geral, não se extraíndo da prova a conclusão de que o bar, onde o réu trabalhava e alegadamente também habitava, contivesse um compartimento acessível ao público em geral e outro reservado à sua intimidade e tampouco que a droga tivesse sido encontrado nesse hipotético compartimento de acesso restrito.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da prova.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente, sendo caso de desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Com efeito, a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), bem como pelo laudo pericial (fls. 48/50), que demonstra ser a substância apreendida cocaína, a qual encontra-se catalogada na lista da portaria 344/98 da Anvisa.

Entretanto, como se verá, a prova não é bastante para evidenciar, com a necessária segurança, que a droga apreendida se destinava à entrega ao consumo de terceiros. O policial militar Everson Claro da Costa afirmou que, na ocasião, juntamente com o policial Rômulo, realizavam abordagem de pessoas pela Rua Anhumas, onde funciona um bar. Em dado momento, percebeu que o réu caminhava em direção ao bar e, ao perceber a presença das viaturas policiais, tentou retornar. Diante da atitude suspeita, o acusado foi revistado, tendo sido encontrada com ele uma porção de cocaína e uma nota de R\$ 20,00. Indagado sobre a droga, o réu admitiu que realizaria a entrega da droga no bar onde estavam efetuando as abordagens. Perguntado sobre a existência de mais droga, o acusado asseverou que existiam outras porções de cocaína em seu estabelecimento comercial, um bar, de sua propriedade. No local, o réu exibiu mais

18 porções de cocaína idênticas àquela encontrada com ele, além de R\$ 151,00. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas. Não conhecia RAFAEL de nenhuma outra ocorrência. Não houve nenhuma denúncia em relação a ele, mas apenas o comportamento de nervosismo dele que os levou a abordá-lo. Antes de proceder à abordagem, não houve nenhuma campana. O bar do réu não aparentava ser uma residência e lá ficava a cerca de 400 metros do outro bar.

O policial militar Rômulo Diego dos Santos Moro declarou que na data dos fatos estavam realizando uma abordagem no bar na Rua Anhumas, que é conhecido pelo tráfico de drogas. Perceberam a presença de um indivíduo que, ao notar os policiais, mudou de direção rapidamente. Por esse motivo, abordaram o indivíduo, que foi identificado como o réu RAFAEL. Em seu bolso foi localizada uma porção de cocaína e a quantia de R\$ 20,00. Indagado e bastante nervoso, o réu admitiu que teria ido até aquele bar para entregar a droga. Indagado se teria mais drogas para o comércio, o réu declarou que era dono de um bar na Rua Vicente Figueiredo e que lá havia mais drogas. Com a autorização do réu, o conduziram até seu bar e o próprio abriu a porta com sua chave. Em um suporte térmico de garrafa, localizaram 18 porções de droga, semelhantes à que o réu portava em seu bolso, e aproximadamente 150 reais em notas diversas no caixa. O réu admitiu que aquela quantia era proveniente do tráfico de drogas. O réu admitiu que estava traficando drogas. Não conhecia o réu. Não houve denúncia contra o réu na data dos fatos, tratava-se de patrulhamento de rotina e abordagem padrão. Não realizaram nenhum tipo de campana. O local era um estabelecimento comercial e a autorização foi dada com o próprio réu abrindo a porta e mostrando a droga. O bar do réu fica a aproximadamente 100 metros do bar onde foi abordado. O suporte de bebida onde foi encontrada a droga estava no balcão do bar, enquanto o dinheiro estava na gaveta do balcão. Não foram encontrados outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. Interrogado em sede policial, o réu RAFAEL negou os fatos. Declarou que, na data dos fatos, caminhava em direção ao bar, quando foi abordado pelos policiais, que o revistaram e localizaram consigo uma porção de cocaína e uma nota de R\$ 20,00. Os policiais passaram a perguntar se havia jogado o restante da droga no quintal de uma mulher, tendo dito que não. Perguntando sobre onde residia, informou que morava em um bar, momento em que os policiais disseram que se encontrassem mais droga, iriam "quebrá-lo", a não ser que fossem levados até o local. Ressaltou que ficou com medo de apanhar, motivo pelo qual levou os policiais até seu bar e exibiu outras porções de cocaína, que estavam embaixo do balcão, que eram para seu consumo. O dinheiro localizado pelos policiais no bar era o remanescente do que havia recebido do Bolsa Família. Asseverou que em nenhum momento admitiu aos policiais a traficância ou a origem ilícita da quantia apreendida, apenas disse que a droga era para uso próprio. Ressaltou que pagou R\$ 20,00 em cada "pino" no dia anterior, na esquina de sua casa.

Em juízo, asseverou que estava com uma porção de cocaína no bolso e R\$ 20,00, e que estava indo tomar uma cerveja no bar próximo à sua casa. Viu que os policiais estavam fazendo abordagem de rotina no bar onde estava indo. Parou perto do portão de uma casa. Os policiais o abordaram e o indagaram se ele havia jogado alguma coisa no quintal daquela casa. O réu disse que não havia jogado nada. Os policiais o indagaram onde o declarante morava e o pressionaram para levá-los até o seu bar, ameaçando de bater caso ele não os levasse até lá. Os policiais disseram que se não encontrassem nada em seu bar, iriam bater em si. Levou os policiais até seu bar, onde foi encontrada a droga e o dinheiro. Alegou que a droga era para uso próprio e que o dinheiro era proveniente do "Bolsa Família", que havia acabado de receber. Disse que parte do dinheiro era proveniente da venda de cervejas em seu bar. Morava no bar. No momento dos fatos estava indo para outro bar para beber cerveja. Iria usar o pino de cocaína no bar para onde estava indo, e gastar os R\$ 20,00 reais com cerveja. Foi abordado quando saía de casa. Relatou que em seu bar foram encontradas 10 porções de cocaína e R\$ 150 reais. Disse que o dinheiro era proveniente da venda de cervejas. Havia recebido 182 reais do "Bolsa Família". Disse que o dinheiro do "Bolsa Família" estava junto com o dinheiro do bar. Explicou dizendo que, ao todo, havia R\$ 151,00, dos quais apenas R\$ 30,00 eram provenientes da venda de cervejas. O bar para onde estava indo fica a aproximadamente 100 m de seu bar. Os fatos

ocorreram por volta das 2 horas da manhã. Perguntado se havia algum motivo para não usar a droga em seu próprio bar e consumir a própria cerveja, disse que costuma sair à noite após trabalhar o dia inteiro. Usava 1 porção por dia. Pagou R\$ 20,00 em cada porção. Disse que pagou R\$ 200,00 reais ao todo comprando a droga. Foram encontrados 10 pinos em seu bar. Indagado sobre o que consta dos autos no sentido de que foram encontrados 18 pinos em seu bar, respondeu que não se lembra da quantidade encontrada. Questionado sobre os valores de cada porção, o valor que alegou ter pago e a quantidade encontrada em sua posse, respondeu que foram encontradas 19 porções sob sua posse. As porções eram suas. Retornou a dizer que pagou R\$ 20,00 por cada porção. Comprou as drogas com o dinheiro do "Bolsa Família" e do bar. No dia anterior à sua prisão havia vendido R\$ 30,00. Tinha um dinheiro de vendas "fiado" e do "Bolsa Família". Seu bar era parado e com pouco movimento. A renda diária do bar é por volta de R\$ 50,00 reais. Seu bar ficava aberto das 11:00 h às 21:00 h. O bar era sua única atividade e fonte de renda, além do "Bolsa Família". Comprou a droga na sexta-feira, um dia anterior aos fatos. Alegou ter comprado as 19 porções para uso próprio e que o preço pago cabia em seu orçamento. Não usa nenhuma outra droga além de cocaína. Usa 1 porção por dia. Relatou que seu bar estava fechado no momento da abordagem policial, que em nenhum momento disse aos policiais que a droga era para venda, e que os policiais não pediram permissão para entrar em seu bar.

Pois bem.

Inicialmente, assinale-se que, como bem se ensina a jurisprudência, que "A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados" (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Em outros termos, a palavra do agente policial vale tanto quanto a palavra das demais testemunhas. Não vale menos, nem vale mais.

Na hipótese em apreço, em que pese o respeitável entendimento ministerial, considero que a prova carreada aos autos, consistente essencialmente nos depoimentos policiais, não foi capaz de demonstrar que o réu "trazia consigo", "guardava" ou "tinha em depósito" as drogas com a finalidade de entregar ao consumo de terceiro.

A uma porque, em que pese os policiais terem afirmado que o réu confessou informalmente que estaria traficando, certo é que a mencionada confissão informal não foi confirmada em juízo e nem mesmo na delegacia de polícia, onde o réu foi ouvido pouco tempo depois de sua abordagem.

Ademais, ainda quanto ao valor probatório da confissão informal, importa trazer à colação recente acórdão da E. 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no bojo da Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556, onde se enfatiza que o valor da confissão condiciona-se à observância à advertência ao preso ou interrogado de que possui o direito ao silêncio. Eis o excerto:

No julgamento do HC nº 80.949/SP, em 30 de outubro de 2001, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a falta de advertência do direito ao silêncio pelos policiais, quando de conversa informal com um preso, havia sido ilegal qualificando a prova obtida como ilícita. O caso envolveu situação de preso temporário que foi levado até uma sala nas dependências do distrito policial onde passou a travar uma conversa com os agentes policiais que tomaram a cautela gravá-la. Entendeu-se no caso que a ausência de advertência do direito ao silêncio havia maculado a prova obtida. Nesse sentido: O interrogatório é a única forma legal de tomada, no inquérito policial, de declarações do indiciado: nele, não há espaço para acolher como declarações do indiciado e menos ainda para validar eventual confissão nelas contida o registro, gravado ou não, de "conversa informal" dele com policiais. A Constituição, no entanto, aditou outra exigência essencial à valoração no processo de declarações do indiciado ou do réu, ao erigir, como garantia fundamental do acusado: Art. 5º (...) LXIII. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer

calado... Elevando aí o nemo tenetur se detegere à alçada de garantia fundamental além da inconstitucionalidade superveniente, consensualmente admitida, da parte final do art. 186, C. Pr. Pen a Constituição na linha da construção da jurisprudência americana, a partir dos famosos casos Escobedo vs. Illinois (378 U.S. 478 1964) e Miranda vs. Arizona (384 U.S. 436 (1969) impõe ao inquiridor, na polícia ou em juízo, o dever de advertência ao interrogado de seu privilégio contra a auto-incriminação. A falta de advertência e, como é óbvio, da sua documentação formal faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o acusado, ainda quando observadas as formalidades procedimentais do interrogatório. Dezoito anos após a prolação do referido julgado, nos autos da Reclamação nº 33.711, julgada em 11 de junho de 2019, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a nulidade do interrogatório o qual havia sido denominado de "entrevista" pela Polícia Federal. Naquele caso, os agentes policiais, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, realizaram várias perguntas ao acusado e cujas respostas foram reduzidas a termo. Mais uma vez entendeu-se que a providência havia desrespeitado o direito ao silêncio pela omissão nas advertências.

Assim, depreende-se que a mencionada confissão informal, sequer confirmada na delegacia de polícia pouco tempo depois, não pode servir como elemento juridicamente útil para embasar a conclusão de que a droga se destinava à venda, e não ao consumo próprio.

A duas porque, quando de sua abordagem, o réu trazia consigo uma única porção de droga, o que confere verossimilhança à sua alegação de que a droga se destinava ao seu próprio consumo e de que teria pago R\$ 20,00 por cada "pino", versão que se manteve constante na delegacia de polícia e em juízo.

Nesse ponto, revela-se relevante acentuar que o bar do réu, local em que maior parte da droga foi apreendida, não é tão próximo do outro bar em cuja direção ele caminhava quando avistado pelos policiais militares. De fato, embora não se possa determinar a distância entre os estabelecimentos, certo é que, segundo o réu, a distância era de cerca de 100 metros, enquanto na percepção do policial militar Everson essa distância era de aproximadamente 400 metros.

Seja como for, parece que os estabelecimentos estavam afastado o suficiente para que, se o réu estivesse levando a droga para venda, não se limitasse a uma única porção, sendo mais factível que, nessa hipótese, levasse quantidade maior, inclusive porque não se tem notícia de algum cliente que tivesse encomendado aquela porção.

Por fim, saliente-se que a quantidade da droga comprovadamente encontrada em poder do réu, apesar de não ser considerada ínfima, não é suficiente para um juízo de certeza da prática do tráfico.

Não se põe em dúvida que, a princípio, não há incompatibilidade com a condição de dependente e a atuação como traficante, havendo, inclusive, hipóteses em que se trafica para manutenção do vício. Entretanto, a compatibilidade retromencionada não afasta a premissa de que a conclusão de que a destinação da droga era o tráfico pressupõe elementos concretos a indicadores de que a droga tinha como destinação a entrega ao consumo de terceiros, o que inexistia no caso sob exame.

Portanto, à míngua de outras provas de que o acusado estaria guardando a droga para posterior entrega ao consumo de terceiros e tendo em vista a pequena quantidade de droga, não havendo elementos que infirmem que os entorpecentes seriam destinados ao consumo próprio, reputo que o cenário é de severa dúvida quanto à destinação da droga com ele encontrada e, conseqüentemente, mostra-se de rigor a desclassificação da conduta.

Tendo em vista a situação pessoal do agente, considero adequada e proporcional, entre as penas previstas no art. 28 da Lei 11.343/06, a imposição ao réu da medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, fazendo-o para, desclassificando a conduta imputada ao sentenciado, CONDENA-LO pela prática do crime descrito 28, caput, da Lei 11.343/06, ao comparecimento a programa ou curso educativo, pelo período de cinco meses.

Arbitro os honorários advocatícios, se o caso, no valor máximo da tabela do convênio.

Determino a restituição do aparelho celular e da quantia em dinheiro apreendidos. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA